

1500476-31.2019.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... réus se associaram para a prática de tráfico de drogas.

Informa ainda, que a ré Letícia, inclusive, foi presa em flagrante pela prática tráfico de ilícito de entorpecentes, apurado nos autos da ação penal nº 0000096-61.2018.8.26.0591, oportunidade em que teria confessado que entregaria as drogas a Felipe e Jeferson (fls. 100/102).

Defesas prévias dos réus Jeferson e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

1500476-31.2019.8.26.0411 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500476-31.2019.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

JEFERSON MASCARELLO FERGUGLIA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

JULGAMENTO CONJUNTO COM O PROCESSO Nº 0000677-29.2021.8.26.0411

FELIPE SILVA DE OLIVEIRA e JEFERSON MASCARELLO FERGUGLIA, qualificados nos autos, foram denunciados perante este Juízo como incurso nas penas dos artigos 33, "caput", e artigo 35 c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Na mesma peça acusatória, LETÍCIA GARCIA DE LIMA, qualificada nos autos, foi denunciada perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 35 c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 19 de maio de 2018, por volta das 10h30min, nas dependências do Centro de Detenção Provisória de Pacaembu, localizado na Vicinal Prefeito Kouitiro Sato, km 7,6, nesta cidade e comarca de Pacaembu, os réus Felipe e Jeferson concorreram para a ré Letícia trouxesse consigo e guardasse 105 (cento e

cinco) gramas de maconha e 121 (cento e vinte e um) gramas de cocaína, drogas que casam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda da peça acusatória que, em período não determinado, mas próximo de 19 de maio de 2018, também nas dependências do Centro de Detenção Provisória de Pacaembu, os réus se associaram para a prática de tráfico de drogas.

Informa ainda, que a ré Letícia, inclusive, foi presa em flagrante pela prática tráfico de ilícito de entorpecentes, apurado nos autos da ação penal nº 0000096-61.2018.8.26.0591, oportunidade em que teria confessado que entregaria as drogas a Felipe e Jeferson (fls. 100/102).

Defesas prévias dos réus Jeferson e Letícia, respectivamente, às fls. 171/179 e 221/227.

Após inúmeras diligências para localização do réu Felipe, foi realizada a citação por edital (fls. 244/245), desmembrando-se o feito em relação a ele (fls. 254) e originando o feito nº 0000677-29.2021.8.26.0411.

A denúncia foi recebida às fls. 261/264.

Após localização do réu Felipe, foi determinada a reunião deste processo com o feito nº 0000677-29.2021.8.26.0411 (fls. 309).

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do réu Jeferson (fls. 360/362 – gravação audiovisual). O réu Felipe, por sua vez, foi interrogado nos autos nº 0000677-29.2021.8.26.0411, conforme termo de audiência trasladado a estes autos às fls. 390/391.

A ré Letícia foi declarada revel (fls. 344/345), pois, citada/notificada às fls. 200, mudou de endereço e não comunicou o Juízo, ausentando-se da audiência de fls. 361/362.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais sob a forma de memoriais.

Alegações finais – Ministério Público

1500476-31.2019.8.26.0411

O representante do Ministério Público apresentou alegações finais nestes autos, às fls. 365/368 (ratificadas às fls. 402), postulando pela improcedência da ação, com a consequente absolvição dos réus Letícia e Jeferson, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

0000677-29.2021.8.26.0411

Nos autos acima, em relação ao réu Felipe, o Ministério Público apresentou memoriais às fls. 347/352, trasladados a estes autos às fls. 392/397 e ratificados às fls. 402.

Em síntese, requer a condenação do réu apenas pelo crime tipificado no art. 33 c.c. o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

No tocante à dosimetria, postula a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e maus antecedentes. Requer ainda, o reconhecimento da agravante da reincidência e da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, assim como o afastamento da causa de

diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Por fim, postula a fixação do regime inicial fechado, sem substituição por pena restritiva de direitos.

Alegações finais - Felipe Silva de Oliveira

Em memoriais apresentados às fls. 353/354 dos autos nº 0000677-29.2021.8.26.0411, trasladados a estes autos às fls. 398/399 e ratificados às fls. 408, o réu negou qualquer participação no delito, postulando a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Alegações finais - Letícia Garcia de Lima

A ré Letícia apresentou alegações finais às fls. 377/381 e as ratificou às fls. 406. Aduz que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação pelos delitos que lhe são imputados. Ao final, pugna pela improcedência da presente ação, com a prolação de sentença absolutória.

Alegações finais - Jeferson Mascarello Ferguglia

O réu Jeferson apresentou suas alegações finais às fls. 371/376. Em síntese, negou a prática das infrações que lhes são imputadas, alegando que as provas carreadas aos autos são insuficientes para sustentar o decreto condenatório. Ao final, pugna pela improcedência da ação, a fim de que seja absolvido, nos termos do art. 386, V, do CPP ou, subsidiariamente, com fundamento no inciso VII, do mesmo dispositivo.

Intimada a ratificar suas alegações finais (fls. 388), a defesa do réu Jeferson manteve-se inerte, conforme certificado às fls. 409.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudos periciais de fls. 20/25, bem como pelos demais elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial (fls. 07/09, 36/41, 65, 87), corroborados com a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, necessário examinar a situação de cada um dos réus de forma particularizada. Vejamos.

A testemunha MARIA CELESTINO DE SOUZA SILVA afirmou que, no dia dos fatos, durante o procedimento de revista para ingresso no estabelecimento prisional, foi identificado um volume junto ao corpo da ré Letícia. Alegou que, ao investigarem o aludido volume, constatou-se a presença de dois invólucros, um contendo substância branca e o outro, verde. Aduziu ainda, que, após serem encontradas as referidas substâncias, a ré lançou no lixo outros dois invólucros idênticos. afirmou que a ré Letícia realizava visitas frequentes e não soube especificar a relação com o sentenciado referido como "galego".

No mesmo sentido depôs a testemunha MARY SATIE REDONDARO. Acrescentou que a ré Letícia, ao ser questionada sobre o destinatário das substâncias, afirmou que seriam entregues ao seu marido, mencionando, também um sentenciado referido como "galego".

Relatada a prova testemunhal, necessário ressaltar que os depoimentos de servidores públicos, como é o caso dos agentes de segurança penitenciária, são plenamente válidos. Neste sentido, o E. TJSP já decidiu nos seguintes termos:

"Como é cediço, nada impede que policiais e guardas municipais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade.

Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública.

Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante por tão grave crime, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito."

(TJSP - Apelação criminal nº 1527289-91.2021.8.6.0228. Rel. Des. Hermann Herschander. Dje.: 06/05/2022).

"Insta consignar ser inquestionável a validade do depoimento prestado pelos Agentes penitenciários. Por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, eles não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante."

(TJSP - Agravo de Execução Penal nº 0000043-87.2022.8.26.0996. Rel. Des. Ely Amioka. Dje. 03/05/2022).

Em seu interrogatório, o réu Felipe Silva de Oliveira afirmou que, à época dos fatos, a ré Letícia era sua amásia, mas não o visitava com frequência na unidade prisional, o tendo feito apenas duas vezes. Alega que não tinha conhecimento de que Letícia levaria qualquer substância para o interior do estabelecimento prisional e que desconhece o réu Jeferson ou qualquer relação dele com os fatos imputados. Sustenta que, ao sair do estabelecimento prisional, conversou com a ré Letícia, a qual, segundo ele, teria confessado que agiu com a intenção de prejudicá-lo, inventando o vulgo "galego".

O réu Jeferson Mascarello Ferguglia, por sua vez, negou os fatos que lhe são imputados. Afirmou que não conhece os corréus Felipe e Letícia e que a sua vinculação aos fatos narrados pode ter decorrido de seu apelido "Galego", o qual, segundo ele, é muito comum no interior dos estabelecimentos prisionais.

Pois bem.

Relatada a prova oral produzida em Juízo, passo ao exame de responsabilidade penal de cada um dos réus, o que faço de forma particularizada, em atenção ao princípio da individualização da pena.

LETÍCIA GARCIA DE LIMA

Em seus memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela absolvição da ré em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, para a caracterização do crime, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência. A reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006, havendo mero concurso de pessoas (STJ - AgRg no HC 541.979/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 13/04/2020).

No caso em tela, não há provas suficientes para indicar que a ré Letícia tenha se associado aos demais corréus com o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas, havendo, a princípio, uma única tentativa, frustrada, de ingresso com os

entorpecentes no estabelecimento prisional.

Sendo assim, por não haver comprovação de associação estável e permanente com os demais corréus, a absolvição da ré Letícia, em relação ao crime de associação para o tráfico, é medida que se impõe.

JEFERSON MASCARELLO FERGUGLIA

A instrução não revelou qualquer participação do réu Jeferson no delito descrito na peça acusatória. Com efeito, todos os depoimentos fizeram referência a detento com vulgo de "galego", sendo impossível constatar se, de fato, referiam-se a Jeferson, que, a princípio, não possui qualquer liame com os demais corréus.

Sendo assim, por não haver provas suficientes da autoria, a absolvição do réu Jeferson é medida que se impõe, invocando-se o princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência, consagrados no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

FELIPE SILVA DE OLIVEIRA

A instrução evidenciou a que a ré Letícia era amásia de Felipe e o visitava no estabelecimento prisional com certa frequência.

Além disso, as testemunhas inquiridas em Juízo, agentes de segurança penitenciária, indicaram que a ré Letícia, ao ser questionada sobre o destinatário das drogas, indicou que os entorpecentes seriam entregues a seu marido e a outro detento, de vulgo "galego".

Ademais, a apreensão das substâncias ocorreu no exato momento que a ré Letícia ingressava no estabelecimento prisional para visitar o réu Felipe, evidenciando ter havido concurso eventual de agentes entre eles. Ressalte-se, ainda, que a ré Letícia integrava o rol de visitas de Felipe, sendo suspensa apenas após a apreensão do entorpecente, conforme demonstram os documentos de fls. 36/39.

Com efeito, os elementos carreados aos autos demonstram que o réu Felipe assumiu a posição de autor mediato do delito, pois, embora não tenha realizado pessoalmente as elementares do tipo penal, se valeu de terceira pessoa (Letícia) para a prática do crime de tráfico de drogas.

Ressalte-se que "é autor mediato quem realiza o tipo penal servindo-se, para execução da ação típica, de outra pessoa como instrumento" (Jescheck, p. 919. In: BITENCOURT, Cezar Roberto. 2014, p. 559). Deste modo, o réu Felipe, na condição de autor mediato, embora não tenha realizado as elementares do tipo penal, serviu-se de terceira pessoa para consumação do delito.

No entanto, ainda que se parta da premissa de que Felipe não assumiu a posição de autor do delito, as provas evidenciam que ele participou da empreitada criminosa, ao menos, na condição de partícipe, induzindo ou instigando a ré Letícia à prática da traficância.

É inequívoca, portanto, a sua responsabilidade penal, pois, nos termos do art. 29 do Código Penal, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

Em caso semelhante, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu nos seguintes termos:

Apelação criminal - Tráfico de drogas. Sentença condenatória pelo delito do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Recurso defensivo de Marcos - Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pedido subsidiário de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, pleito de aplicação do redutor de pena (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), com fixação de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa. Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito da ré Isadora, que foi surpreendida portando o entorpecente quando passava por revista para realizar visita ao estabelecimento prisional onde seu namorado, o corréu Marcos, estava recolhido. Agentes Penitenciárias que constatarem a presença de objeto estranho no corpo da ré, por meio de 'scanner'. Acusada que retirou o invólucro, o qual estava introduzido em sua vagina, onde estava o entorpecente. Apreensão de um invólucro contendo maconha, pesando 47,33 gramas. Corrê que afirmou que pretendia visitar apenas seu namorado Marcos. Corréu Marcos que concorreu para o crime, sendo o destinatário da droga no estabelecimento prisional - Manutenção da condenação de rigor. Grifo nosso. (TJSP - Apelação Criminal nº 1500067-34.2018.8.26.0591. Rel. Des. Ely Amioka. Dje.: 02/02/2021).

Por fim, não há como acolher a alegação de Felipe no sentido de que a ré Letícia teria levado as drogas ao estabelecimento prisional com o propósito exclusivo de prejudicá-lo. Isso porque, ao fazê-lo, ela causou prejuízo a si própria, incorrendo também nas penas do crime de tráfico de drogas.

Desarrazoado, portanto, supor que a ré Letícia assumiu deliberadamente o risco de ser condenada, simplesmente, com o propósito de causar prejuízo a seu amásio Felipe, pois, ao fazê-lo, inevitavelmente, acabaria sendo a principal prejudicada, eis que processada criminalmente.

Sendo necessária a condenação pelo cometimento de tráfico de drogas, passo à dosimetria da pena a ser imposta ao réu FELIPE SILVA DE OLIVEIRA.

Na primeira fase de dosimetria, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a pena-base deve ser fixada 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo legal, pois os dados da vida pregressa do réu indicam a presença de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 145/146 (condenação transitada em julgado nos autos nº 0001322-91.2011.8.26.0512, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas).

Ressalte-se que são considerados maus antecedentes as condenações definitivas que não caracterizam reincidência, seja pelo decurso de 5 anos após o cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I, CP), seja pelo fato de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito.

Sendo assim, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, para o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase de dosimetria, conforme certidão de fls. 145/146, verifica-se que o réu é reincidente (condenação transitada em julgado nos autos nº 3003862-14.2013.8.26.0505, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). Com efeito, ocorre a reincidência quando o agente comete novo crime, depois do trânsito em julgado da condenação por crime anterior, agravando-se a pena nos termos do art. 61 e 63 do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes que possam incidir no presente caso.

Deste modo, diante da agravante da reincidência e não havendo atenuantes a serem valoradas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Por fim, na terceira e derradeira fase de dosimetria, incide a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.373/06, o qual dispõe que “as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais [...]”.

Ademais, incabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.373/06, posto que a figura do “tráfico privilegiado” não se aplica às situações em que o réu é reincidente ou ostenta maus antecedentes.

Assim, diante da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, aumento a pena no percentual mínimo (um sexto), fixando-a, definitivamente, em 07 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 793 dias multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Considerando a condição econômica do réu, o valor diário da multa será correspondente ao mínimo legal, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, além da reincidência delitiva, a pena aplicada ultrapassa a 4 anos, impedindo a aplicação do art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO PENAL que ensejou a distribuição dos processos autuados sob os nº(s) 1500476-31.2019.8.26.0411 e 0000677-29.2021.8.26.0411, o que faço para:

a) Com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER a ré LETÍCIA GARCIA DE LIMA da acusação de ter cometido no delito tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

b) Com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu JEFERSON MASCARELLI FERGUGLIA, da acusação de ter praticado o crime tipificado no art. 33, “caput”, e artigo 35 c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal.

c) CONDENAR o réu FELIPE SILVA DE OLIVEIRA como incurso no art. 33, “caput” c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 793 dias multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

d) Com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu FELIPE SILVA DE OLIVEIRA da acusação de ter cometido no delito tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/06;

Diante do julgamento conjunto, traslade-se cópia desta sentença aos autos nº 0000677-29.2021.8.26.0411, certificando-se.

Em atenção à consulta formulada pela serventia às fls. 409 destes autos e tendo havido a condenação do réu Felipe Silva de Oliveira, caso necessário, providencie-se o traslado de todas as peças processuais dos autos nº 0000677-29.2021.8.26.0411 que se façam necessárias para a expedição de guia de recolhimento nestes autos, certificando-se.

Em relação à consulta formulada pela serventia às fls. 363 dos autos nº 0000677-29.2021.8.26.0411, com o traslado de cópia desta sentença àqueles autos e certificação do julgamento conjunto, expeça-se certidão de honorários em favor advogado do réu Felipe Silva de Oliveira, bem como dos demais advogados que atuaram neste feito, no patamar máximo, em consonância com os atos praticados.

No tocante aos réus LETÍCIA GARCIA DE LIMA e JEFERSON MASCARELLI FERGUGLIA, acaso presos por este processo, expeça-se alvará de soltura "clausulado", salvo se estiverem presos por decisão proferida em outro processo.

Com relação ao réu FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, o mesmo poderá apelar em liberdade, um vez que assim respondeu ao processo, inexistindo circunstância nova a justificar a segregação, ao menos nesta fase procedimental.

Transitada esta em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade) .

P.I.C.

Pacaembu, 16 de maio de 2022.